

0001040-40.2017.8.26.0028

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217- A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º).

Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001040-40.2017.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001040-40.2017.8.26.0028

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 016/2017 - DISE DEL SEC GUARATINGUET, 77/2016 - DISE DEL SEC GUARATINGUET

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Augusto Elache dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia DIEGO AUGUSTO ELACHE DOS SANTOS, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 07:30 horas, Rua Totó Barbosa, nº 238, Jardim Paraíba, nesta urbe, DIEGO AUGUSTO ELACHE DOS SANTOS, tinha em depósito, para vender, medicamentos de ação anabolizante e outros para indução do sono, sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada, devidamente apreendidos (fls.12/14), conforme laudo pericial, relatório de análise e Nota Técnica (fls.86/91, 92/129 e 260/262).

De acordo com a narrativa fática trazida na denúncia, Apurou-se que, em cumprimento

dos mandados de busca e apreensão, os Policiais Civis Edinei Motta e Alexandre Ricardo de Oliveira Ferrari encontraram na residência do DENUNCIADO, bem como, em seu estabelecimento comercial VITAFORM, 2 frascos de 7-Keto, 1 frasco de DHEA, 1 frasco de 7-KETO, 1 frasco de Predator Plexx, 8 frascos de DHEA 50mg, 6 frascos de DHEA 25mg, 2 frascos de Beta-Alanine, 1 frasco de Melatonin APPLIED NUTRICEUTICA, 10 frascos de Melatonin ON, 1 frasco de Melatonin NATROL, 8 frascos de Tribulus NOW SPORTS, 3 frascos Tribulus ON, 9 frascos de Bulgarian Tribulus, 1frasco de HMB e 9 frascos de Trib-X, sem registro na ANVISA, e 2 frascos de produto sem identificação e de procedência ignorada.

Na ocasião, os agentes fiscais de renda da Fazenda Pública Paulo César Guimarães e Otávio Condino Júnior presenciaram as apreensões, os quais não constataram nenhuma irregularidade fiscal quanto as mercadorias (fls.237 e 238).

Interrogado em solo policial, o então investigado afirmou que, mesmo sem autorização da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, havia uma grande demanda em relação a esses produtos, que seriam receitados por médicos e nutricionistas, e por isso não notou a irregularidade (fls.16).

Denúncia recebida em 09 de setembro de 2019 (fls. 1/3).

Citado, o acusado ofereceu Defesa Prévia, pleiteando por sua absolvição sumária e apresentou o rol de testemunhas a serem arroladas (fls. 327/336).

Em audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, Paulo César Guimarães e Otávio Condino Júnior, via carta precatória de fls. 372/443.

Foi redesignada audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 01/07/2021 (fls.444).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as outras testemunhas arroladas pela acusação Edinei Motta e Alexandre Ricardo de Oliveira Ferrari, a testemunha de defesa Rodrigo Baracho Zanetin e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada (fls. 565/573)

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis (fls. 578/601).

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado no crime previsto no artigo 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal.

Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como as qualificadoras descritas na denúncia.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 07/10), Auto de Exibição/apreensão (fls. 11/14, 15/17), Termo de Declarações (fls. 18, 19/20), Requisição de IC (fls. 27/28), Termo de Declarações de Roan Marcos dos Santos Correa (fls. 16, 167), Termo de Declarações de DIEGO AUGUSTO ELACHE DOS SANTOS (fls. 19/20), Documentos de Instauração/apreensão (fls. 21/26, 33/60), Auto de Entrega (fls. 31/32), Relatório de Investigações da Delegacia de Polícia (fls. 62/79), Documentos de Instauração/apreensão - Ato Circunstanciado de Busca Domiciliar (fls. 87), Laudo Pericial (fls. 89/94 95/132), Termo de Depoimento de Edinei Motta (fls. 147/148), Termo de Depoimento de Alexandre Ricardo de Oliveira Ferrari (fls. 154/155), Fotografia (fls. 203/219),

Relatório Final oferecido pelo Delegado de Polícia (fls. 221/222), bem como pela Nota Técnica nº. 210/2021/SEI/GADIP-CG da ANVISA (fls. 539/544).

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Comprovada, à saciedade, a materialidade do crime, a autoria, por seu turno, foi demonstrada pela prova oral produzida em audiência

Passo a análise da prova oral produzida.

Interrogado, o réu DIEGO AUGUSTO ELACHE DOS SANTOS alegou em juízo que:

Tá, eu vou passar todos os fatos como aconteceram e como se explica, do meu ponto de vista. Eu tenho um comércio voltado para a parte de suplementação, não é medicamento. Faz mais de 15 anos que eu trabalho com isso. Eu nunca, de forma alguma, vendi nenhum produto ilícito na minha loja. Eu nunca vendi um tipo de anabolizante em minha loja, e nunca venderei, mesmo hoje, numa situação bem mais complicada que na época dos fatos. É, o que que ocorreu. Na época, eu recebi uma denúncia que eu estava vendendo, no meu comércio, anabolizantes, entendeu. Nunca fiz venda de nenhum tipo de anabolizantes. Em Aparecida, em Guará, onde eu tinha a segunda loja, eu tinha um funcionário que era fisiculturista atleta, onde foi constatado já pelo interrogatório, com os policiais, onde foi encontrado na casa do funcionário essa questão de anabolizante, do uso. Eu não sei se ele fazia comercialização na casa, se ele fazia comercialização na minha loja, porque tendo lojas em outras cidades, eu não ficava presente na loja onde ele trabalhava. Essa denúncia foi criada em cima de uma situação que eu nunca apliquei. Referente aos itens, eu tenho hoje, cadastrado no meu sistema, três mil itens cadastrados. Não todos que eu vendo atualmente. Mas tenho três mil cadastrados. Quando teve essa denúncia, que eu vendia anabolizantes, os policiais foram na minha casa, foram na minha loja, onde seria constatada a venda dos anabolizantes, e começaram a fazer uma coleta de mais de cem itens. Foi coletados inúmeros itens, muitos itens. E todos esses itens foram levados para Delegacia, onde a escrivã me pediu que tudo que eu conseguisse captar de indícios ali, que eu pudesse comprovar a veracidade do produto tal, me apresentasse e seriam excluídos. A maioria dos itens, grande parte deles, como a parte fiscal foi acionada, eu tenho nota de tudo. Na época, eu tinha nota de tudo, toda minha loja, toda legalizada. Todos os produtos são pagos impostos, corretamente. Nunca deixei a desejar, referente a isso, nenhum ponto de vista. E, alguns itens, como eu tinha uma indicação muito grande desses itens, por ingenuidade na época, eu comprava uns itens em sites, Mercado Livre, em on-line, para mim atender meu cliente. O cliente chegava lá e preciso de uma melatonina, preciso de uma Whay e uma glutamina. Na época. Hoje, sim, hoje estou consciente disso. Na época, eu acabava passando produto para meu cliente, com intuito de atendê-lo. Porque não vinha um cliente lá e eu pegava um produto embaixo do balcão escondido, esses produtos estavam cadastrados, estavam na prateleira. Pra mim, com até o nutricionista, ou qualquer outro médico, vocês podem consultar, eles prescrevem isso todos os dias. Todos os dias chega para a gente todos os tipos de produtos. Óbvio que são lícitos. Produtos ilícitos não é indicado. Em nenhum momento eu oculteí esses produtos, eu vendia eles por baixo do pano. Os produtos estavam na prateleira. E quando os policiais chegaram na minha casa, onde ficava próximo à loja, os produtos que foram encontrados lá, onde eu não tinha estoque. Minha loja tem três por cinco, onde, tipo assim, na época, como eu tinha uma demanda boa de venda, eu tinha que colocar em minha casa alguns itens porque eu não tinha condicionamento na loja. Minha loja era muito pequena. Então, os fatos aconteceram nesse formado. E quando na época eu passei e por não saber, indicava esses itens, eu fui um pouco ingênuo. Eu não via Tribullus, Melanina, Betalamina, HMB, como produto ilícito, porque até hoje, como na época, eles são comercializados normalmente. Normalmente, são comercializados na internet e em situações assim muito favoráveis. Comprar e receber na sua casa, e não precisa apresentar receita, nada. Como laboratórios também fazem isso no dia-a-dia nas farmácias. Eles vendem e fazem isso todos os dias nas farmácias. Não tinha conhecimento [itens relacionados na portaria da ANVISA como medicamentos e sem registro], como até hoje eles são comercializados. Hoje, eu tenho conhecimento. Não se encontra na minha prateleira,

faz muitos anos. E nem embaixo de balcão, nem escondido faço a venda desses produtos. E esses produtos eles são todos os dias prescritos por médicos, todos os dias. Não só eles como produtos ilícitos. Óbvio que daí não é encontrado em site, mas todos os dias eles são comercializados. E todos os sites hoje, você encontra no Mercado Livre, você encontra no Netshoes. No Extra, já cheguei a encontrar no Extra. Até em anexo, a gente acabou anexando muitos sites onde são encontrados. E não só esses produtos, todos os outros que foram citados, todos são encontrados. E eu acabei, tipo assim, em prol do meu cliente, eu acabei colocando. É uma fração muito pequena, esses itens em prateleira, onde não estavam escondidos, e onde é uma quantidade muito reduzida de uma gama mercadoria que eu trabalho. Era mais para, ingenuamente, atender o meu cliente numa forma que eu não sabia. E mais, tipo assim, por ser prescrito por nutricionista e médico, para mim passa a impressão que é um produto lícito. Comercializado, não em nosso País, nos Estados Unidos, países europeus, tipo assim, em freeshops são vendidos, são vendidos em farmácias, vendidos em grandes lojas. Livrementemente [Dhea], livrementemente são vendidos sim. Encontrei alguns sites nacionais, em lojas americanas, em sites americanos são vendidos. Hoje, um pouco mais complicado, devido a demanda do dólar, devido. Mas são vendidos, comercializados sim. Esses produtos, eles ficavam na minha loja como qualquer um outro produto, entendeu, de todos os laboratórios que eu trabalho. Em nenhum momento eles eram taxados como hormônios anabolizantes. Eles eram indicados por médicos. Esses produtos eles que, não como que o cliente chegava e eu encomendava. Como eu tinha uma demanda de prescrição, tinha uma demanda de clientes na loja, eu acabava comprando por sites, algumas coisas onde, tipo assim, eu não tenho no meu contador todas essas notas, porque as notas vinham de empresas assim direto para o computador. Então, esses produtos como eu acabava comercializando e comprando ele pela internet, eu tinha algumas peças na loja, era quatro de uma, dois de outra. Outras eu tinha uma quantidade um pouquinho maior, que eu acabava comprando ele ou pelo Netshoes, comprava pelo Mercado Livre, comprava ele, na época, já cheguei a comprar até pelo Magazine Luiza. Até hoje a gente encontra esses produtos para serem comercializados. Como foi na época que eu acabei comprando alguns itens para mim deixar na minha loja, para atender aos clientes. Na época que ocorreu, eu não sabia dessa real situação. Fiquei sabendo depois, devido alguns itens foram taxados lá como a ANVISA não permitia e eu só comprava esses itens, não de forma clandestina, comprava nesses sites, eu só comprava porque tinha indicações de médicos lá e nutricionistas que indicavam isso para os clientes. De forma nenhuma, nem antigamente, onde estava mais favorável como hoje, eu passar a perna num cliente, vender um produto ilícito, e ter fins lucrativos, de forma nenhuma. Eu só passei a comercializar esses itens pelo fato que alguns médicos, nutricionistas, alguns educadores, professores, indicavam, e eu acabava, para eu atender esses clientes, eu tinha lá na minha loja. Como que se, a gente for verificar, hoje, noventa por cento das lojas, não sei se sabe ou não, comercializam isso livrementemente. A partir do momento que eu fiquei ciente da situação, não tenho mais esses itens. Não comercializo mais esses itens, e nem por baixo do pano, porque eu não preciso fazer uso dessas, dessa venda desses produtos, na minha loja. Era nos sites, nos sites. Comprei no Mercado Livre. Como esses sites grandes, são Marketplace, algumas empresas que mandavam nesses Marketplace, entendeu. Isso faz muito tempo, acho que faz 5 anos isso, 4 anos, entendeu. Eu consigo fazer uma comprovação duma compra desse item, apresentar essa compra, como tivesse comprado, entendeu. Sim, é o mesmo [exibindo o medicamento Dhea, vendido pelo Magazine Luiza]. Sim [exibindo o medicamento Dhea, vendido pelo Extra], o princípio ativo é o mesmo, são várias marcas, vários laboratórios, na verdade. Sim, sim, é o mesmo produto [exibindo o medicamento Dhea, vendido no Carrefour], são os mesmos itens. É a mesma [exibindo o medicamento Dhea, vendido pelas Casas Bahia]. Nenhuma resistência [aos policiais], fiquei surpreso. Eu nunca passei por isso na minha vida, é uma situação que, tipo assim, não quero mais passar. Eu não esperava isso, em nenhum momento eu vendi produto ilícito, vendi produto falsificado. Tentei falsificar, produzi algum produto, passar a, é ter fins lucrativos do meu cliente, jamais. Nunca tive problema nenhum referente a isso. Atendi, expliquei. Tudo que foi pedido, foi feito. Nenhuma me hesitei de atendê-lo de forma nenhuma. Olha, como

foi citado até aí, os policiais chegaram na parte da manhã, bem cedo, tinha saído para comprar pão, alguma coisa assim. Eles chegaram na minha residência. Da minha residência até a loja fica menos de dois minutos. Muito perto. Então, acabei atendendo ali. Depois eles foram para loja. Falei que tinha alguns itens que não era, não era, já deixo bem claro isso, esses produtos ilícitos. Os produtos foram encontrados na loja. Em casa eram produtos que eu não conseguia conduzi-los na loja. Nenhum momento esses produtos que foram citados foram encontrados na minha casa, encontrados na loja, na prateleira. Tava na prateleira, todos os itens. Não, não, a denúncia que eu recebi, no dia, que tinha um mandado, tava fazendo venda de anabolizante na minha loja e, como não foi constatado, encontrado, nenhum tipo de anabolizante, já foi até citado em outros depoimentos, foram encontrados pelos policiais na casa do funcionário, eles captaram muitos itens da loja, captaram. Mas anabolizantes, como citados pelos policiais, não foram encontrados nem na minha casa, na minha loja, nada. Não [os policiais não tinham

conhecimentos técnicos sobre os medicamentos]. Não, até pelo fato que eles levaram muitos itens, levaram bastante coisa, muitos itens. Não tinha, não tinha conhecimento, como eles, eu também não sabia, na época, quais itens eram. Foi feita de todos [conferência dos itens]. Na verdade, de todos. Eu não observei o trabalho, que eu fiquei sabendo lá, que não tinha que eles levarem a diante, tava tudo documentado, tudo com nota no dia. Foi feito, foi coletado. Eu liguei para meu contador. Eu levei todas as pastas que eu tinha no contador lá. Todas as notas batiam com todas as caixas que eles estavam verificando com a documentação lá. Não teve nenhuma irregularidade. No dia, não teve nenhuma que eles passaram lá para os policiais, depois, que me passaram. Para mim, diretamente, não, foi passado para os policiais, que não ia dar sequência, porque todos os itens verificados estavam todos corretamente cadastrados, todos com, perante lá as notas apresentadas, tudo batendo. Hoje, o meu ganha pão na verdade eram as lojas. Hoje, eu não tenho, só tenho uma loja. Tinha numa outra cidade, uma academia. As outras, eu acabei fechando. A loja também, essa loja que foi constatado, não encontra-se, ela fechou. Eu tenho uma loja só, a filial foi fechada, só tenho a matriz. Hoje, eu dependo diretamente só da loja. Meu ganha pão é a loja. Eu tinha a loja em Aparecida, e tinha a de Guará, que foi constatada também nos Autos. Foi verificado lá também. Hoje, só tenho a de Guaratinguetá. É bem localizada no Centro. Tenho alvará, tudo certinho, dos Bombeiros. Tenho funcionários. A loja fica bem localizada. Eu consegui, ainda, a localização dessa loja. Eu não consegui manter a filial, acabei mantendo essa matriz. Hoje, é o que eu consigo manter né. Ela fica bem localizada, fica no Centro da Cidade. Eu tenho dois funcionários. Então, ela no Centro, é até privilegiada, onde eu consegui me segurar, devido até a localização, onde tem um fluxo maior de pessoas.

A testemunha de defesa Rodrigo Baracho Zanetin disse em juízo que:

Sou nutricionista esportivo. Conheço [esses tipos de suplementos]. Tribullus é uma planta, classificado com fitoterápico, pelo meu conhecimento. Os outros, acho que você falou Melatonina, é um hormônio, mas, a princípio, eu não sei dizer para você ao certo se é um anabolizante no sentido esteroide. Agora, no sentido anabólico, vai depender do uso da pessoa, da alimentação, do treino. Com relação aos suplementos, é um suplemento que muitas pessoas utilizam. Olha, eu, particularmente, já vi em alguns sites, como, dar os nomes aqui das empresas. Vi no site da Americanas, site da Submarino e no site, se não estou enganado, das Casas Bahia. É, como hoje, e na Netshoes também. Hoje, a linha de suplementação, ela está sendo muito vendida e explorada no e-commerce, então você encontra com facilidade. Não, pelo que eu saiba não, pelo que eu saiba não. Não há necessidade de prescrição. Então, eu já vi, eu já atendi pessoas que utilizam. Mas eu, na minha conduta profissional, eu não prescrevo. Até porque eu gosto muito de trabalhar com a parte da alimentação. As vezes, algumas vitaminas, alguns minerais, dependendo dos exames, da anamnese que é feita em consultório, aa gente, eu faço prescrição dessas vitaminas e minerais. E suplementos a base de proteína, como Whey. Mas, num modo geral, esses outros suplementos, eu não prescrevo. Que eu saiba não, não conheço [pacientes que passaram mal usando esses suplementos]. Sim, antes de eu ser nutricionais, eu. Em 2017, antes de eu ser nutricionais, eu, na graduação, a gente

sempre teve acesso a essas informações, de suplementos, pessoas que utilizam. A gente sempre via e comentava, então, até então, a princípio, sempre foi vendido. Então, esse é um suplemento que encontra facilmente em site. Apesar de ser um hormônio, como a melatonina, são encontrados facilmente de uma forma bem idônea, sem um caráter negativo assim, e sem também a prescrição, sem uma solicitação de um profissional. Eu, inclusive, já vi em sites, o Dhea.

Contudo, apesar da evasiva formulada pelo acusado, entendo que a autoria delitiva restou bem demonstrada pelos incisivos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Otávio Condino Júnior declarou em juízo que:

compareceu a delegacia de Guaratinguetá numa sexta- feira na parte da tarde, não lembrando o dia certo, disse que não acompanhou a apreensão pela Polícia Civil, ele apenas foi com os agentes verificar uma possível irregularidade de mercadorias, sob o aspecto de tributo e ICMS, e, informaram que seria uma residência de um dos sócios e depois no estabelecimento comercial do próprio sócio. Chegando no local conduzido pela Polícia Civil juntamente com a testemunha Paulo César Guimarães, chegaram a conclusão por amostragem que em termos tributário, ao verificar algumas mercadorias e as notas que foram fornecidas a eles, havia uma certa regularidade, não entrando no mérito de ser irregular ou não, ou se a ANVISA tinha algum registro ou não, até mesmo por não terem condições técnicas. Contudo, ao analisarem as mercadorias (que estavam em frascos e em caixas de papelão), constataram que estava tudo conforme a nota fiscal. Ele diz não se lembrar de ter acompanhado a apreensão da mercadoria pela Polícia Civil, apenas foi conduzido para verificar se havia irregularidade sobre aspecto tributário. Questionado pela Defesa, disse que ao chegar ao local a pessoa (não se lembra quem era) não apresentou resistência.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Paulo César Guimarães disse em juízo que:

é fiscal de renda da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Respondeu que é de praxe que a Polícia Civil e, principalmente, a Polícia Rodoviária quando faz apreensão de mercadoria sem documentação fiscal, chamar a Secretaria da Fazenda para fazer essa apreensão. Foi passado esse serviço para ele e seu colega, encaminharam-se para a casa e para a loja do réu, sendo que a loja estava vazia, mas na residência encontraram alguns produtos estranhos, tais como anabolizantes e remédios, verificaram e algumas coisas encontraram documentação fiscal. Não caracterizou de ponto de vista fiscal e tributário, que havia alguma desregulamentação. Só fizeram uma verificação superficial, mas não podiam fazer mais nada, pois não tinham condições técnicas. Questionado pela Defesa, disse que não foram tratados de forma mal educada pelo réu e não chegou a falar qual era a sua função para eles. Não possuem escopo para identificarem se o produto é ilícito.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Edinei Motta disse em juízo que:

Foi cumprir mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial com endereço nos autos. Se dirigiram também à residência do acusado, onde ele mostrou os medicamento e suplementos que se encontravam na residência. Todos os produtos que foram encontrados em poder do acusado foram apreendidos e levados até a delegacia. Informou que a investigação foi do seu colega Alexandre e que somente o acompanhou no cumprimento mandado de busca e apreensão. Não soube informar das investigações prévias, porque estava afastado por doença, somente acompanhando a diligência de busca e apreensão. Informou que os produtos foram apreendidos na residência do acusado e uma loja na rua totó Barbosa. E que a maior parte dos produtos foram encontrados na estabelecimento comercial de Aparecida e alguns outros na residência do acusado. Não se recorda exatamente dos produtos que foram apreendidos. Também não se recorda se alguns dos produtos de produtos com prazo de validade vencida. Não conhecia o acusado anteriormente. Informou que também foram a uma outra loja em Itaguaçu, do acusado ROAN. Não se recorda das mercadorias apreendidas em poder de ROAN. Também foram a uma loja do acusado em Guaratinguetá. Não se recorda de ter apreendido qualquer produto na loja de Guará. Afirma não se recordar da pessoa chamada ROAN. Não sabe dizer se ROAN era funcionário da loja VITAFARM. Esteve na

loja de Aparecida. Não se recorda se os produtos foram encontrados sem notas fiscais. Durante a ocorrência dois fiscais da receita acompanharam os trabalhos. Não sabe informar exatamente o material apreendido. Trabalhou três anos e meio na DIIIESE. Não se recorda exatamente quantas investigações ocorreram sobre esses fatos, acredito ser apenas duas. Sobre os anabolizantes, somente se recorda de ouvir falar que era para uso próprio do acusado. Não se recorda da apreensão de anabolizantes em poder de Diego. Não eram lojas clandestinas, lojas normais, lojas bem conhecidas com placas identificadoras. O acusado não resistiu ao cumprimento do mandado. Não apresentou qualquer resistência. Não estava muito alterado. A testemunha arrolada pelo Ministério Público Alexandre Ricardo de Oliveira Ferrari disse em juízo que:

Foi expedido mandado de busca e apreensão por informações e denúncias que eram vendidos produtos que não eram registrados na ANVISA. Em cumprimento ao mandado foram encontrados diversos produtos em sua loja, na sua residência, e em outra loja que possui em Guaratinguetá. Relatou que primeiramente o cumprimento foi na rua totó barbosa, onde era uma de suas lojas. Indagado a respeito de outros produtos. Ele informou que havia mais produtos em sua residência e também em uma loja que mantém em Guaratinguetá. A nome da loja seria VITAFORM. É uma loja que vende produtos suplementos alimentares para pessoas que praticam exercícios físicos e buscam aumento de massa muscular. Não o conhecia anteriormente. Informou saber de alguns medicamentos que são proibidos pela ANISA. Foram apreendidos diversos produtos. Foi encontrado, inclusive, na residência do investigado ROAN, alguns anabolizantes, os quais não se recorda exatamente o nome. Existe outro investigado ROAN, que faz fisiculturista, onde foram encontrados os anabolizantes (na residência de ROAN). Com Diego não foram encontrados anabolizantes. Foram várias denúncias anônimas que no local dos fatos eram vendidos anabolizantes e outros tipos de remédios para performance esportivo. Em conversas informais com pessoas conhecidas, os policiais foram alertados de que as denúncias eram procedentes. Participou da investigação desde o início. A investigação era para apurar o comércio ilícito de substâncias anabolizantes. A informação que eles tinham é que os anabolizantes eram vendidos na loja VITAFORM e pelo ROAN. Afirmou que encontrou os anabolizantes foram encontrados na residência de ROAN. O alvo da investigação era direcionado à venda e comercialização de anabolizantes. ROAN trabalhava na loja VITAFORMA cuja loja é de propriedade do DIEGO. Os produtos encontrados nas lojas do acusado possuíam notas fiscais, fatos esses que foram atestados pelo fiscais tributários que acompanharam a diligência. Narrou que alguns produtos não possuíam registros na ANVISA. Na época que trabalhava na DIIIESE, substâncias anabolizantes eram parte das investigações tocantes às substâncias entorpecentes. Não conheço especificamente o produto tribules terrestres. O acusado, em nenhum momento, se negou a mostrar os produtos que se encontravam em seu poder. Afirmou que se trata de uma loja normal de produtos destinados a suplementos, lojas regularizadas. Não fez outra operação nos mesmos moldes da aqui investigada. Os produtos foram apreendidos no comércio. A maior parte foi encontrado na loja de Aparecida. Ora, dos relatos apresentados pelas testemunhas extraem-se vários elementos que, concatenados, dão a certeza da autoria. Os policiais civis responsáveis pela operação esclareceram que receberam denúncias da comercialização irregular de suplementos alimentares e medicamentos com substâncias anabolizantes tanto no endereço do investigado chamado ROAN como também na loja de suplementos alimentares VITAFORMA.

Cumprе ressaltar que toda diligência policial originou-se da emissão de mandado de busca e apreensão, deferido pela 1ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de número 0003650-15.2016, fruto, portanto, de sólidas denúncias do acontecido, tanto é que a diligência foi frutífera.

Os policiais relataram uma quantidade grande e diversa de produtos (medicamentos e suplementos alimentares) tanto na loja VITAFORMA quanto na residência do acusado Diego. Ambos esclareceram que a maior parte do material apreendido foi encontrada no estabelecimento comercial VITAFORMA localizado à Rua Totó Barbosa, 238, Jardim Paraíba, em Aparecida, estabelecimento que pertencia pelo ao acusado DIEGO. Foi esclarecido pelos policiais que eles já tinham notícias do comércio irregular

de tais produtos, contudo, ante a grande quantidade de produtos, procederam a apreensão do encontrado e encaminharam a delegacia especializada para exame pericial.

No tocante à idoneidade de depoimentos de Policiais Cíveis, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Nesta senda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos ." (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189, in TACRIM - As mais recentes decisões nº 5, Jun/97, p.07

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Portanto, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a condenação do acusado, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Ademais, não há que se falar em contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que não entraram em contradição em momento algum.

Além disso, é esse o entendimento dos Tribunais:

"Pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboçar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias nos pontos secundários que são frutos da imperfeição do psiquismo humano" (JUTACRIM, vol. 95/26, rel. Segurado Braz).

"O importante é como nos diz DELLAPIANE, verificar se embora descorando dos detalhes mínimos concorra a final nos pontos essenciais, nas circunstâncias mais importantes do fato que cada uma, isoladamente reconstituiu" (Nova Teoria da Prova - 2ª ed., Ed. Konfino, 1958 - pág. 145).

Ora, como se vê, a versão trazida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado é lógica e coesa, não trazendo quaisquer elementos que a

ponham em cheque. Assim, nada há que se discutir quanto à forma como se deram os fatos.

Ambas as testemunhas confirmaram, de modo coerente e lógico, confirmaram que o réu foi flagrado quando em posse das substâncias descritas no auto de exibição e apreensão e posteriormente analisados por meio do laudo pericial.

É clara também a tipificação da conduta, nos exatos termos do que constou da denúncia.

Tem-se que o crime previsto no art. 273 do Código Penal possui como bem juridicamente protegido a incolumidade pública, consubstanciada, no caso, especificamente, na saúde pública, tratando-se, ademais, de infração penal de perigo presumido ou de mera conduta, não necessitando de resultado naturalístico. O tipo penal traz quatro ações nucleares típicas: falsificar, corromper, adulterar ou alterar. Como objeto material temos o produto destinado à fins terapêuticos ou medicinais.

De acordo com o que estabelece o §1º-A, incluem-se entre os produtos a que se refere o caput: os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico em geral.

Já o §1º-B prevê a sujeição às mesmas penas do caput de quem importa, vende, expõe a venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos que, apesar de não falsificados, corrompidos, alterados ou adulterados, encontram-se nas seguintes condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; É o produto que, apesar de não corrompido, não foi devidamente registrado no órgão sanitário. Trata-se aqui, de norma penal em branco, já que a exigência de registro é determinada pelo poder público, em normas próprias.

Consoante todas as provas trazidas nos autos, revelou-se que o denunciado, no dia 23 de setembro de 2016, no endereço descrito na denúncia, estabelecimento comercial VITAFORMA, explorado comercialmente por DIEGO, tinha em depósito, para vender, produtos, sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada, devidamente apreendidos (fls.12/14), conforme laudo pericial, relatório de análise e NOTA TÉCNICA.

Segundo o auto de exibição e apreensão (fls. 15/17)

- 2 frascos de 7-Keto, 1 frasco de DHEA,
- 1 frasco de 7-KETO, 1 frasco de Predator Plexx,
- 8 frascos de DHEA 50mg,
- 6 frascos de DHEA 25mg,
- 2 frascos de Beta-Alanine,
- 1 frasco de Melatonin APPLIED NUTRICEUTICA,
- 10 frascos de Melatonin ON, 1 frasco de Melatonin NATROL,
- 8 frascos de Tribulus NOW SPORTS,
- 3 frascos Tribulus ON,
- 9 frascos de Bulgarian Tribulus,
- 1 frasco de HMB e

9 frascos de Trib-X, sem registro na ANVISA,

e 2 frascos de produto sem identificação e de procedência ignorada.

Tais substâncias apreendidas foram submetidas a exames periciais (fls. 95 a 132), que revelaram ser substâncias que podem ser usadas para fins terapêuticos ou medicinais, além de não possuírem registro no órgão de saúde pública e/ou vigilância sanitária.

O laudo descreve a existência de 2 (dois) produtos sem identificação. Além disso descreveu a existência de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, quais sejam: 7-KETO; DHEA, Predator Plexx, DHEA 50mg e DHEA 25mg.

A conclusão pericial é corroborada pela nota técnica da ANVISA (fls. 539/544) que descreve:

"Os produtos, 2,6,7,19,26,27 e 28 citados no Relatório de Análise 523.974/2016 contém as substâncias elencadas nas Listas da Portaria nº 344/98."

"Também foram realizadas pesquisas para verificar a situação do registro das substâncias elencadas nas Listas da Portaria nº 344/98, quais sejam: DHEA Acetato-7-one, DHEA e 2,17^a-dimethyl-5a-androsta-1-em-17b-ol-3-one. Para tanto, foram

considerados os seguintes termos: "7-keto", "Keto", "DHEA", "Predator Plexx", "formebolona", "bolasterona", estes últimos foram consultados haja vista seus ésteres os componentes dos produtos 7-keto e Predator Plexx, respectivamente. Não foram localizados registros válidos, tampouco pleiteados para qualquer dos componentes supracitados." (grifo nosso)

Pois bem, do exposto se observa que a conduta perpetrada pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito.

A prova oral supra exaustivamente transcrita, aliada aos demais elementos probatórios presentes nos autos, são capazes de formar, com a certeza e segurança necessária e exigível, a convicção desse Julgador no sentido de que o réu possuía em depósito tais substâncias, para comercialização, sem o devido registro no órgão sanitário competente.

E não há qualquer possibilidade de reconhecimento da figura culposa, por latente do que produzido nos autos que o réu tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, não agindo por imprudência, imperícia ou negligência.

Da mesma forma, não se pode cancelar a tese defensiva de que a conduta praticada pelo acusado é socialmente aceita, o que levaria a exclusão da tipicidade, na vertente material, de sua conduta.

É cediço que o direito penal é regido por princípios, tais quais a intervenção mínima e a fragmentariedade, que exigem que o direito penal seja aplicada somente às situações em que se mostre absolutamente necessário e que não hajam soluções extrapenais eficazes para tutelar a situação de risco.

No caso dos autos, ainda que se possa considerar a venda de medicamentos sem o registro nos órgãos competentes ou mesmo em desacordo com as normas estabelecidas pelos órgãos públicos de vigilância sanitária, não é de se olvidar que tal conduta é socialmente danosa.

Notadamente, inúmeros são os relatos de danos à saúde ocasionados pelo uso não controlado de substâncias anabolizantes e de suplementos alimentares, uso esse feito sem a devida orientação médica. Admitir que o comércio clandestino de tais produtos é conduta socialmente aceita e por isso, o direito penal deveria se abster de intervir, é ir de encontro com o que há de mais relevante no estado de direito, que é o cumprimento das leis para garantia do bem estar social.

A Suprema Corte pátria já teve a oportunidade de se debruçar sobre questões como a alegada, asseverando que o fato de a sociedade tolerar a prática do delito em questão não implicaria dizer que o comportamento do paciente poderia ser considerado lícito.

1. Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade. 2. O impacto econômico da violação ao direito autoral mede-se pelo valor que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer com a "pirataria", e não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e ilegal. 3. A prática da contrafação não pode ser considerada socialmente tolerável haja vista os enormes prejuízos causados à indústria fonográfica nacional, aos comerciantes regularmente estabelecidos e ao Fisco pela burla do pagamento de impostos. 4. In casu, a conduta dos pacientes amolda-se perfeitamente ao tipo de injusto previsto no art. 184, §2º, do Código Penal, uma vez foram identificados comercializando mercadoria pirateada (CD's e DVD's de diversos artistas, cujas obras haviam sido reproduzidas em desconformidade com a legislação). (STF. HC 118.322/MS. Rel. Min. Luis Fux. Julgamento em 22.10.2013)

Portanto, não há que se acolher a tese defensiva de atipicidade material da conduta do acusado.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DO ART. 273, DO CP. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito.

O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos.

A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º).

Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade.

Dessa forma, alinhado ao recentíssimo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 979.962/RS, de relatoria do Eminente Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese para fins de repercussão geral: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária."

Portanto, declarada em cunho incidental a inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal, deve-se aplicar, pelo efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a redação originária, a qual previa pena de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, além da multa.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do ar. 59, do Código Penal, observo ser o réu primário, de bons antecedentes, conduta social normal, sem elementos negativos quanto à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito. Logo, fixo a pena base em seu patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena nos patamares acima indicados.

Da mesma forma, ausentes causas de aumentos ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena aplicada nos seguintes patamares: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Consoante o que determina o art. 33, §2º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO.

Em relação ao valor do dia multa, observa-se que o apenado é indivíduo com ensino superior completo, empresário com múltiplas lojas e reside em bairro de padrão elevado (Jardim Paraíba) da cidade de Aparecida/SP, logo, tais circunstâncias denotam possuir capacidade econômica elevada, razão pela qual fixo o valor do dia multa em 1/2 (meio) salário mínimo nacional.

Tendo em vista que o sentenciado é primário, cumpridos os demais requisitos para a concessão da benesse, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nestes termos, presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 e seus incisos do Código Penal, substituo cada pena corporal por uma restritiva de direitos, na forma do art. 45, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal, consistentes em: prestação pecuniária consistente no pagamento de 6 (seis) salários mínimos à entidade com destinação social, a ser

fixada pelo juízo da execução penal.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado DIEGO AUGUSTO ELACHE DOS SANTOS, por ter praticado fato tipificado no Artigo. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, dia multa fixado em ½ salário mínimo nacional, em regime inicial ABERTO, pena essa substituída por uma 01 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no montante de 6 (seis) salários mínimos a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. O réu poderá apelar em liberdade.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art.

336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA